

1501137-44.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... não foi visto em atitude típica de tráfico, não trazia consigo quantidade expressiva de entorpecente ou quantia exacerbada em dinheiro. Dessa forma, os fatos agora apurados estão a demonstrar a prática do uso de entorpecente para uso próprio. Impõe-se, pois, a parcial procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501137-44.2021.8.26.0571 - Controle 2021/001202

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Contravenções Penais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RODRIGUES ALEIXO DOS SANTOS

Data da Audiência:

03/03/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ausente o acusado Rafael Rodrigues Aleixo dos Santos, que se encontra em liberdade e foi devidamente intimado às fls. 184. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foi ouvida a testemunha Marcelo Garcia da Costa arrolada pelas partes. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Vanclei Benedito Fogaça, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O depoimento foi registrado pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Decreto a revelia do réu e não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 10h13min, na Rua Adão Mariano Gomes, 443, Jardim Brasil, nessa cidade e Comarca de Itapetininga, trazia consigo e guardava, para entrega posterior a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 12 porções de "cocaína", sob a forma de "crack", com peso líquido de 1,82g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (fls. 118) e apresentou defesa prévia (fls. 122/125). A denúncia foi recebida em 18/10/2021 (fls. 131/132) e o acusado foi citado (fls. 184). Durante a instrução foi ouvida uma testemunha. O réu não foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), auto de constatação

(fls. 21/2) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 98/101). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em depoimento policial, o réu disse que havia comprado 12 pedras de "crack" por R\$ 100,00. Afirmou que a droga era para seu próprio consumo (fls. 05). O réu é revel. A prova oral não é contundente em relação à traficância. De fato, diz a denúncia que policiais militares faziam patrulhamento e avistaram o denunciado parado em uma esquina. RAFAEL, ao notar a presença policial, esboçou uma fuga, o que gerou forte suspeita nos agentes públicos e motivou a abordagem. Realizada busca pessoal, os policiais encontraram nos bolsos da blusa de RAFAEL 12 porções de "crack", além da importância de R\$ 140,00 em dinheiro, um alicate e uma chave de fenda. O policial ouvido nesta oportunidade corroborou o histórico da denúncia. Vale ressaltar, contudo, o fato de ter dito não ter visto o acusado em meio à venda de entorpecente, sequer cercado de outras pessoas. Assim, a prova não é firme ao demonstrar que o acusado realizava o comércio ilegal. Aliás, não foi visto em atitude típica de tráfico, não trazia consigo quantidade expressiva de entorpecente ou quantia exacerbada em dinheiro. Dessa forma, os fatos agora apurados estão a demonstrar a prática do uso de entorpecente para uso próprio. Impõe-se, pois, a parcial procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu ostenta Maus antecedentes e é reincidente (fls. 34/43). Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu como incurso no art. 28, da Lei de Tóxicos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. JUIZ. O ora defendido foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. A ação penal, no entanto, não merece prosperar.

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11343/06: A acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta quantidade entorpecentes e como o réu não foi preso mantendo contato com pessoas, mas apenas - de acordo com os depoimentos - na posse de pequena quantidade de entorpecente, a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico "para consumo pessoal". Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presume que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Ainda, o fato de parte das substâncias estar embalada individualmente nada indica: se alguém vende a droga fracionada, alguém a compra também fracionada, de modo não há como inferir a mercancia apenas em razão desta circunstância. Destaque-se, por fim, que o réu declarou que possuía os entorpecentes para seu consumo pessoal e que disse que, possivelmente, ia vender uma parte depois para poder comprar mais drogas posteriormente, pois fazia uso de crack e conseguiu apenas uma parte da droga em crack. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais.

2. DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS: Do que consta nos autos, depreende-se que não há qualquer fundamento jurídico que obste a diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Mesmo que o réu seja reincidente, deve ser aplicada a causa de diminuição em questão. Em primeiro lugar, por não ser reincidente específico - a condenação anterior é por delito contra o patrimônio (art. 155 do CP). Em segundo lugar, porque deixar de aplicar a referida causa de diminuição exclusivamente em razão da recalcitrância, significaria incorrer em ofensa aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. A não aplicação da causa de diminuição acarretaria a seguinte situação: se primário, ao réu seria atribuída uma pena de 01 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão; já, se reincidente, ser-lhe-ia arbitrada pena superior a 06 (seis) anos. É evidente a desproporcionalidade das sanções, atentando-se, em especial, ao fator de

discriminação adotado (reincidente). Se para os demais crimes há, normalmente, em razão da reincidência, uma diferença, entre primários e reincidentes, de apenas 1/6 na pena, não há razão lógica para que apenas no tráfico se estabeleça um desnível superior a 300%. Ademais, entendendo-se pela inaplicabilidade do dispositivo acima, estaria uma mesma circunstância fática (reincidência) servindo, a um só tempo, como agravante e causa impeditiva da diminuição, representando, assim, duplo apenamento em flagrante infração ao princípio do non bis in idem. O peso da reincidência é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 da pena, sendo dois terços dela aplicada em função da reincidência (ou seja, por fato anterior). Esta desproporção é inconstitucional, ainda, porque aprecia para a dosagem da pena valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência, estaríamos admitindo a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (em face de seus antecedentes) e não em razão do que o agente faz. Pelo exposto, requer-se a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 3. DA

DOSIMETRIA: Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer-se: a) a fixação da pena-base do acusado no patamar mínimo legal; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, caso ela seja valorada pela sentença; c) seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º do Código Penal, tendo em vista o objetivo da norma de punir, de maneira mais branda, aquele que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida e aquele considerado “pequeno traficante” – o que é o caso dos autos; d) seja fixado regime inicial aberto e substituída a pena por restritiva de direitos; e) seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, nos moldes do que estabelece o artigo 8, item 2, alínea “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica, visto não haver razões para a manutenção da prisão preventiva. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. RAFAEL RODRIGUES ALEIXO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 10 h e 13 min, na Rua Adão Mariano Gomes, n. 443, Jardim Brasil, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, doze porções de “crack”, com peso de 1,82 gramas. Notificado, fls. 118, o Réu apresentou defesa preliminar cumulado com pedido de liberdade provisória, fls. 122/125, o MP manifestou-se sobre o pedido, fls. 129/130. A denúncia foi recebida e o pedido de liberdade, deferido, fls. 131/132. O Órgão Acusador requereu a decretação da prisão preventiva tendo em vista estar o Réu em situação de rua, fls. 163, o pedido foi deferido, fls. 164. O Réu foi citado por edital, fls. 171. O mandado de prisão foi cumprido, fls. 172/175, e a seguir o Réu

foi citado pessoalmente, fls. 184. Durante a audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes. Foi decretada a revelia do Réu. Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a desclassificação, no que foi acompanhado pela Defesa. É o relatório. DECIDO. A ação é parcialmente procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 08/11, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 12, no Laudo de Constatação, fls. 21/22, bem como no Exame químico-toxicológico n. 275.560/2021, fls. 98/101, constatando-se a presença do princípio ativo cocaína. Marcelo Garcia da Costa, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu, parado em uma esquina, o qual, ao ver a viatura, empreendeu fuga; os policiais foram ao encalço do Réu, e, ao realizarem a abordagem, encontraram dinheiro e um kit com doze pedras de “crack”; com o Acusado os policiais localizaram um alicate e uma chave de fenda. O Réu disse que a droga era para consumo pessoal e o dinheiro era proveniente de venda de material reciclável. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a parcial procedência é medida que se impõe, pois, com o Acusado, houve apreensão de porções de entorpecentes em pequena quantidade, compatíveis com a destinação própria, havia poucas unidades. Tratando-se de usuário de entorpecentes, óbvio que as drogas lhe pertenciam, notadamente porque foram apreendidas consigo, todavia, em virtude da

pequena quantidade e ausentes informações de venda, a conclusão é que as drogas eram destinadas ao uso pelo Acusado. Houve apreensão de dinheiro, todavia, ao ser indagado pelos policiais, afirmou que era proveniente da venda de material reciclável. Em síntese, em virtude de todas essas circunstâncias, não se autoriza a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas e mister é a desclassificação da conduta imputada ao Réu para a tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. ART. 28, DA LEI 11.343/2006: Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia e o faço para condenar RAFAEL RODRIGUES ALEIXO DOS SANTOS, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Defiro a liberação do dinheiro. Sem condenação nas custas. O Réu está em liberdade e, neste momento, ausentes as razões para a decretação da custódia cautelar, poderá nessa condição interpor eventual recurso. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 03 de março de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA